

1505752-79.2021.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... outros policiais, visando combater o tráfico de entorpecentes existente na Rua Mário Bataiola, nº 501, no condomínio residencial "Dr. Paulo Lúcio Nogueira", defronte ao bloco D-1, realizaram diligências e avistaram o réu, que portava uma pochete preta, evidenciando que estava praticando o tráfico. Quando chegaram, mesmo com a viatura descaracterizada, o acusado tentou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1505752-79.2021.8.26.0344 - lauda

CONCLUSÃO

Em 18 de janeiro de 2022, faço os autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. Josiane Patricia Cabrini Martins Machado. Eu, Juliana Baccelli Fernandes Cunha, M364719, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505752-79.2021.8.26.0344 - Controle 2021/001139

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YURI LUIZ COSTA DA SILVA

Vistos.

YURI LUIZ COSTA DA SILVA (RG: 58.674.732, filho de Jair da Silva Junior e Edith Costa Pereira) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 22 de junho de 2021, por volta das 9h15, na Rua Mário Bataiola, nº 501, em frente ao Bloco M2, nesta cidade e Comarca de Marília/SP, trazia consigo e guardava, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal e regulamentar, 3,49g (massa líquida) de cocaína e 327,03g (massa líquida) de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, que contém tetrahydrocannabinol, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica.

Recebida a denúncia (fls. 115/117), o réu foi citado (fls. 158) e apresentou defesa preliminar (fls. 162/173).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, sendo, o acusado, interrogado ao final.

Alegações das partes apresentadas em audiência, conforme termo retro.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade e a autoria delitivas foram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 3), boletim de ocorrência (fls. 12/17), auto de exibição e apreensão (fls. 25/26), fotografias (fls. 27/31), laudo de constatação (fls. 34/37), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 94/99) e pela prova oral colhida.

Os policiais civis Wellington e André declararam, na fase inquisitiva, que, na data dos fatos, no período da manhã, por volta das 9h, em companhia de outros policiais, visando combater o tráfico de entorpecentes existente na Rua Mário Bataiola, nº 501, no condomínio residencial "Dr. Paulo Lúcio Nogueira", defronte ao bloco D-1, realizaram diligências e avistaram o réu, que portava uma pochete preta, evidenciando que estava praticando o tráfico. Quando chegaram, mesmo com a viatura descaracterizada, o acusado tentou empreender fuga, mas foi detido defronte ao bloco M-2, sendo que, no interior da pochete, encontraram um tubo de ensaio com maconha fragmentada, 8 (oito) pinos com cocaína, 4 (quatro) pinos com crack, 55 (cinquenta e cinco) porções de maconha, tipo "bananinha", sendo 39 (trinta e nove) com adesivo "G", 13 (treze) sem adesivo e três maiores, além da importância de R\$7,00 (sete reais) em dinheiro. Durante diligências na residência do acusado, visando obter sua documentação e comunicar os fatos à sua família, seu genitor afirmou que no interior do quarto que ele ocupava havia um pote de vidro contendo maconha fragmentada, o qual foi localizado e apreendido. Informalmente, o réu disse que foi apreendido por tráfico de entorpecentes quando era menor de idade. Em juízo, acrescentou, o investigador Wellington, que o local em que avistaram inicialmente o acusado é bastante conhecido pela prática do tráfico de drogas, havendo diversas prisões em flagrante naquela localidade. Ainda, relatou que, entre os blocos D e G, há um ponto de venda de drogas conhecido como "biqueira do Bloco G/biqueira do G", letra que constava em diversos entorpecentes, conforme já mencionado em suas declarações prestadas na fase policial. Acrescentou que não conhecia o acusado antes dos fatos aqui narrados, bem como que, no local, apenas se encontrava o réu quando do flagrante. André, da mesma forma, disse que conhecia apenas de vista o acusado, não o tendo abordado anteriormente.

O acusado, por sua vez, na delegacia, alegou que os entorpecentes encontrados pelos policiais no interior da pochete não lhe pertenciam, afirmando que, com ele, havia apenas um tubo de ensaio com um pouco de maconha fragmentada, além de um isqueiro. Ressaltou que já foi apreendido quando menor de idade por envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive ficou detido na "Fundação Casa" por um ano; entretanto, atualmente não está mais envolvido com tal crime. Após sua prisão, os policiais foram até sua residência e seu genitor indicou a eles um pote de vidro que continha maconha fragmentada, tendo afirmado que era para seu consumo. Ademais, negou que estivesse no local praticando o tráfico, desconhecendo a quem pertenceria a pochete contendo a droga apreendida pelos investigadores. Por fim, relatou que em momento algum correu quando os policiais chegaram. Em seu interrogatório judicial, afirmou que havia se dirigido ao local dos fatos para adquirir drogas, pois é usuário de maconha. Ressaltou que, embora já tivesse um pouco do entorpecente (o qual serviria seu consumo até o final daquele dia) em um pote em sua casa, a fim de não ter que se dirigir novamente ao ponto de venda de drogas, decidiu sair naquele momento para garantir que tivesse o suficiente. Todavia, ao chegar na "biqueira", viu que os que estavam promovendo a venda se evadiam com a chegada do carro da polícia. Destacou que a pochete com drogas apreendida poderia ser de um desses rapazes que até então estavam por ali. Disse que não correu e que os policiais localizaram consigo apenas um tubo de ensaio contendo maconha. Perguntado a respeito de seu consumo de drogas, afirmou fumar cerca de 20 (vinte) cigarros de maconha por dia. Asseverou trabalhar em uma serralheria, sem registro em carteira, auferindo cerca de R\$ 70,00 a R\$ 80,00 por dia, porém, naquele dia, não foi trabalhar em razão de que havia combinado com sua tia de irem a uma agência bancária resolver um problema com seu cartão. Esclareceu que reside apenas com seu genitor no apartamento que era de sua avó e que, atualmente, seu pai trabalha com reciclagem, pois perdeu a moto que utilizava para trabalhar como mototaxista. Disse que, desde que preso, não usa qualquer droga, a despeito de não ter feito qualquer tratamento para drogadição. Por fim, asseverou que não conhece os policiais que o abordaram.

Ora, da prova produzida, verifica-se que ela é conclusiva e indica, com segurança, a traficância exercida pelo réu.

Primeiro, oportuno advertir que os policiais são agentes públicos que gozam de presunção de legitimidade no exercício da função, de modo que seus depoimentos

devem ser acolhidos, pois não se vislumbram elementos que indiquem que pretendiam, na verdade, prejudicar pessoa inocente, contra quem não nutrem inimizade ou hostilidade, relatando fatos inverídicos e “plantando” provas. Neste sentido: “Vale destacar que os policiais são agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente senão se demonstrou interesse concreto da sua parte na incriminação do acusado. A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no sentido de que 'o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional' (RT 752/589).” (Apelação nº 0030961-20.2015.8.26.0576, 10ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Tristão Ribeiro, j. 30.6.2017).

No caso dos autos, verifica-se que os depoimentos dos policiais foram harmônicos, lógicos, coerentes e livres de dúvidas desde a fase inquisitiva, repetindo-se na fase judicial, nada indicando intenção deliberada de prejudicar o réu.

Quanto ao mérito propriamente dito, destaca-se que o acusado praticou conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, ou seja, trazia consigo e guardava, para entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes sem a devida autorização legal ou regulamentar.

Do exame dos autos, extrai-se que, na data dos fatos, no período da manhã, visando ao combate do tráfico de entorpecentes na Rua Mário Bataiola, nº 501, no condomínio residencial “Dr. Paulo Lúcio Nogueira”, defronte ao bloco D-1, local já conhecido pela venda de drogas (tanto que já efetuadas diversas prisões em flagrante anteriormente), investigadores da DISE realizaram diligências quando avistaram o acusado, que portava uma pochete preta, em atitude suspeita. Esclareceram que conduziam uma viatura descaracterizada, mas, ainda assim, foram percebidos pelo acusado, que tentou empreender fuga, sendo detido defronte ao bloco M-2. Após revista, no interior da pochete que o réu trazia consigo, encontraram um tubo de ensaio com maconha fragmentada, 8 (oito) pinos com cocaína, 4 (quatro) pinos com crack, 55 (cinquenta e cinco) porções de maconha tipo “bananinha”, sendo 39 (trinta e nove) com adesivo “G” (letra que identifica que o entorpecente pertence ao ponto de venda de drogas conhecido como “biqueira do Bloco G”/ “biqueira do G”), 13 (treze) sem identificação e três maiores, além da importância de R\$ 7,00 (sete reais) em dinheiro. Posteriormente, na residência do acusado, após indicação de seu genitor, localizaram um pote de vidro contendo mais maconha fragmentada em seu quarto.

Quanto à tese de invasão de domicílio levantada pela defesa, verifica-se que, tanto os policiais quanto o próprio acusado afirmaram que o ingresso foi autorizado pelo genitor, que, ainda, teria indicado a presença de mais entorpecentes dentro do quarto do acusado. Assim, inexistente razão para que se ponha dúvida acerca da lisura no proceder dos investigadores, motivo pelo qual resta afastada referida tese. Da mesma forma, não convence a narrativa apresentada pelo acusado de que os entorpecentes, exceto aquele contido dentro do tubo de ensaio, não lhe pertenceriam, mas sim a terceiros que correram com a chegada do veículo dos policiais, eis que não há razões para se duvidar do relato dos investigadores, que não eram conhecidos pelo réu, ou seja, não há qualquer indicação de inimizade que o fariam incriminar falsamente suspeito.

Outrossim, a tese de que seria mero usuário e não comercializaria drogas restou refutada pela prova dos autos. Com efeito, sequer ficou comprovado o exercício de atividade lícita por ele, ressaltando-se que improvável que Igor, de fato, laborasse em uma serralheria (o que poderia ter sido comprovado documentalmente ou mesmo por simples declaração do suposto “patrão”), eis que flagrado em dia de semana (22 de junho de 2021), em horário de trabalho (9h15), não comprovando, da mesma forma, que justamente naquele dia iria com sua tia resolver um problema em agência bancária.

Sobre o elemento subjetivo do tipo, consigna Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho, na página 101 do livro “Lei de drogas comentada artigo por artigo” (3ª ed. São Paulo: Método, 2012): “O crime é essencialmente doloso. Não

se exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando a consciência e a vontade de realizar alguma das condutas descritas. Embora a expressão 'tráfico de drogas' esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoito verbos-núcleos mencionados. O tipo, portanto, não exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando o conhecido 'dolo genérico'".

No mais, a solução legal para se concluir pela distinção entre o simples usuário de entorpecentes e o traficante vem da análise dos elementos constantes do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006. Com base no que está ali descrito é possível identificar em qual condição se encaixa o acusado.

Neste contexto, observo que a quantidade de entorpecente apreendida (3,49g - massa líquida - de cocaína e 327,03g - massa líquida- de Cannabis Sativa L), o alto poder vulnerante de uma das drogas, além da forma de embalo (já prontas para entrega a consumo de terceiro) e as circunstâncias da prisão (que se deu em local conhecido pela venda de entorpecente após o réu avistar a viatura policial e tentar fugir), revelam, que se trata, o acusado, de traficante.

Assim, considerando todos os elementos trazidos aos autos (quantidade de entorpecentes apreendida; natureza altamente vulnerante de uma das drogas; acondicionamento típico para venda; quantia em dinheiro; e local já conhecido como ponto de venda de drogas), convenço-me, indubitavelmente, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, de que o réu praticava o tráfico ilícito de entorpecentes, não se tratando, pois, de mero usuário.

Ressalte-se que o possível uso de drogas não elimina a incidência do crime mais grave. Pelo contrário. O crime mais brando fica absorvido pelo tráfico. Ou seja, eventual condição de usuário não exclui a de traficante: "Oportuno dizer que a condição de usuário não afasta, necessariamente, a de traficante, pois, como é sabido, na maioria das vezes, os usuários se valem do comércio ilícito de entorpecentes para sustentar o próprio vício, de modo que uma conduta não exclui a outra." (TJSP - Apel. 0006495-60.2008.8.26.0655; j. 11.4.2013).

Quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, de se levar em conta que não incide o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois o histórico de envolvimento do acusado com o tráfico (foi apreendido quando menor), bem como a quantidade de entorpecentes e as circunstâncias da prisão, já examinadas, indicam o exercício constante de atividades ilícitas, devendo, pois, ser afastado o benefício. O que se quer dizer é que a quantidade e a forma de acondicionamento da droga encontrada com o réu indicam a prática profissional do crime em questão.

Portanto, não é possível considerar "traficante de primeira viagem" ou traficante sem expressiva relevância no exercício da atividade quem traz consigo tamanha quantidade de drogas para distribuição a terceiros, quantidade, inclusive, capaz de atingir número expressivo de usuários, o que revela a importância e o desvalor da conduta, suficientes a afastar a benesse legal. Neste sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC 124.646/SP.

Ainda, destaco que, conforme decidido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (cuja ementa se encontra colacionada a seguir), o histórico de envolvimento do agente na prática de atos infracionais, quando menor, pode justificar a não aplicação da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AÇÕES PENAIIS EM CURSO OU CONDENAÇÕES ANTERIORES NÃO DEFINITIVAS. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. 2. A Terceira Seção pacificou entendimento no

sentido de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (EResp 1.431.091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 1º/2/2017). 3. Ademais, é reiterada a jurisprudência desta Corte no sentido de que o histórico de envolvimento do agente na prática de atos infracionais, quando menor, pode justificar a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas. 4. Hipótese em que o redutor não foi aplicado com base no fato de o paciente possuir diversos registros anteriores, como atos infracionais praticados quando menor, inclusive por tráfico de drogas, além de recente condenação criminal pela prática do mesmo delito, a denotar dedicação a atividades criminosas. 5. A valoração negativa da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos constitui fator suficiente para a determinação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 685.372/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)

Portanto, caracterizado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, provada a autoria e materialidade, e afastadas as teses defensivas por tudo que se expôs passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena. Atenta aos requisitos do artigo 42 da Lei 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, observo que a quantidade de droga apreendida com o réu, além do alto poder vulnerante de uma delas, autorizam a fixação da reprimenda em patamar superior ao mínimo, eis que demonstram o alto grau de periculosidade do agente e de reprovabilidade da conduta. Assim, estabeleço a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, aumentando a pena mínima prevista no tipo em 1/6 (um sexto). Na segunda fase, não há agravantes. Reconheço a atenuante da menoridade relativa, motivo pelo qual torno a pena no mínimo legal em relação a ele: 5 (cinco) anos de reclusão.

No terceiro estágio, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 500 (quinhentos) dias-multa, cada qual no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo, reajustados a partir da data do fato, critério previsto no artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta. Primeiro, porque o crime praticado pelo acusado é daqueles equiparados aos hediondos, sendo totalmente incompatível com o sistema mais rigoroso previsto na Lei 8.072/90 e na própria Lei Antitóxicos a concessão de quaisquer benefícios ou a fixação de cumprimento inicial de pena em regime mais brando. Ademais, de se levar em conta a gravidade da conduta praticada e os antecedentes do acusado, que já se envolveu na prática de ato idêntico quando menor. Neste sentido: “Caráter hediondo do delito, daí a correta fixação do regime fechado e a negativa da substituição da corporal por restritivas de direitos, até mesmo em razão da quantidade da pena.” (Apelação nº 0013049-83.2015.8.26.0196, 10ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Tristão Ribeiro, j. 30.6.2017).

Atenta ao teor da Lei 12.736/12, a detração de pena e a progressão de regime deverão ser oportunamente analisadas em sede de execução penal, no Juízo competente para tal, com base na guia de recolhimento, na folha de antecedentes e nas informações carcerárias do condenado, após a realização dos devidos cálculos. Como bem se sabe, a progressão não se dá automaticamente, dependendo do requisito subjetivo atestado pelo Diretor do estabelecimento em que se encontra o preso, de boa conduta carcerária, além do preenchimento do lapso temporal necessário. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar YURI LUIZ COSTA DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Nego ao réu o apelo em liberdade. A gravidade em concreto da conduta por ele praticada, já mencionada quando da decisão que converteu a prisão em flagrante em

prisão preventiva e nesta decisão confirmada, demonstra a necessidade de continuidade da custódia. A ordem pública, pois, deve ser preservada, evitando-se a reiteração da conduta, bem como se deve acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face do crime e de sua repercussão. Ademais, sabedor da condenação, pode buscar meios de eximir-se da aplicação da lei penal.

Assim, recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido.

Declaro o perdimento, em favor da União, na forma do artigo 63 da Lei 11.343/06, do valor apreendido (R\$ 7,00 - sete reais), por ausência da comprovação da origem lícita do dinheiro (fls. 25).

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para o cumprimento do estabelecido no inciso III do artigo 15 da CF.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, se o caso.

Expeçam-se os demais ofícios e comunicações de praxe.

P.I.C.

Marília, 24 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA